

0001310-06.2017.8.26.0306

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Natália Berti

Comarca: José Bonifácio

Foro: Foro de José Bonifácio

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 14/03/2022

... Data de registro: 10/03/2016).

Apelação. Tráfico de drogas. Absolvição por insuficiência probatória. Necessidade. Ausência de elementos que comprovem a participação do apelante na traficância. Corréu que assumiu isoladamente a propriedade dos entorpecentes. Dúvida razoável que deve prevalecer em favor do acusado. Insuficiência probatória caracterizada, nos termos do artigo 386, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de José Bonifácio

Foro de José Bonifácio

2ª Vara

Av. Monsenhor, 1000, Jardim das Palmeiras - CEP 15200-000, Fone: (17)3245-3348,

José Bonifacio-SP - E-mail: josebonif2@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

0001310-06.2017.8.26.0306

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 142/2017 - Delegacia de Polícia de José Bonifácio

Autor:

Justiça Pública

Réu:

TUESLEY SILVA CUNHA e outro

Vítima:

RAFAELA FERNANDA COSTA

Aos 14 de março de 2022, às 14:00 horas, na sala virtual de audiências e utilizando-se da ferramenta Microsoft Teams, onde presente se encontrava a Exma. Senhora Doutora NATÁLIA BERTI, MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de José Bonifácio/SP, comigo, Escrevente a seu cargo, ao final nomeado. Aberta a audiência com as formalidades de praxe, verificou-se a presença do I. Representante do Ministério Público, DR. CÉSAR BOCUHY BONILHA. Presentes o(a) acusado(a) JEFERSON CAETANO PENHA e sua defensora nomeada, DR(A). LÍGIA VANZELA DE FREITAS - OAB/SP 320.178. Presentes o(a) acusado(a) TUESLEY SILVA CUNHA e seu defensor constituído, DR. RONICLEI MALISSI MIRANDA - OAB/SP 425.854. Abertos os trabalhos, pela MMª. Juíza de Direito foi oportunizado aos réus exercerem seu direito de entrevista prévia com seus respectivos Defensores de forma virtual e reservada, nos termos do artigo 185, § 5º, do CPP. Em seguida, foi ouvida a vítima RAFAELA FERNANDA COSTA, nos moldes do artigo 217 do Código de Processo Penal, sem a presença dos acusados, conforme solicitado. Em seguida, foi ouvida a testemunha EDUARDO ROBERTO CONCEIÇÃO. Em seguida, foram interrogados os acusados. ADVERTÊNCIA: Excepcionalmente e em razão da pandemia COVID-19, considerando a necessidade de dar celeridade à tramitação dos processos, esta audiência de instrução foi realizada por videoconferência. O Juízo e as partes fizeram uso da ferramenta Microsoft Teams recomendada pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo para este fim. A audiência foi

gravada em sistema audiovisual e será armazenada no programa SAJ, junto a este termo, sendo desnecessária a transcrição, nos termos do § 2º do artigo 405 do Código de Processo Penal. Em seguida, pela MMª. Juíza de Direito foi dito que: Digam as partes acerca de eventual diligência cuja necessidade se origine das circunstâncias ou fatos apurados na presente instrução. Em seguida, pelo I. Dr. Promotor foi dito que: MMª. Juíza de Direito, nada a requerer. Em seguida, pelo(a) Dr(a). Defensor(a) do(a) acusado(a) foi dito que: MMª. Juíza de Direito, nada a requerer. Em seguida, pela MMª Juíza de Direito foi dito que: Declaro encerrada a instrução. Em seguida, o Dr. Promotor manifestou-se em alegações finais, gravado pelo sistema audiovisual. Em seguida, o(a) Dr(a). Defensor(a) manifestou-se em alegações finais, gravado pelo sistema audiovisual. Em seguida, pela MMª. Juíza de Direito foi proferida a seguinte sentença, publicada em audiência:

Vistos.

TUESLEY SILVA CUNHA e JEFERSON CAETANO PENHA, devidamente qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incurso nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, porque, na madrugada de 10 de dezembro de 2016, na Rua Três de Maio, Rodoviária, Centro, nesta cidade e comarca de José Bonifácio, TUESLEY SILVA CUNHA e JEFERSON CAETANO PENHA, qualificados a fls. 71 e 51, agindo em concurso, previamente ajustados e em unidade de desígnios, subtraíram, para eles, mediante violência exercida contra a vítima Rafaela Fernanda Costa, um celular, marca Samsung, modelo G531, cor branca, pertencente a ela. Segundo se apurou, os denunciados seguiram a vítima e Jeferson a segurou e tampou sua boca, enquanto Tunesley subtraiu o seu aparelho celular. Constatou-se que a vítima estava na rodoviária aguardando um amigo, quando ali chegaram Tunesley, conhecido da vítima, morador de rua que fica no antigo supermercado Dionísio, e Jeferson.

Os denunciados ficaram no local conversando com a vítima, sendo que quando a mesma foi embora, ambos a seguiram, momento em que Tunesley tentou pegar o seu celular e não conseguiu, quebrando a tela; na segunda tentativa, Jeferson segurou Rafaela, tampou sua boca, e Tunesley roubou seu aparelho celular.

A vítima reconheceu os denunciados por meio de fotografia como sendo os autores do delito (Auto de reconhecimento fotográfico a fls. 06).

A denúncia foi recebida em 03 de dezembro de 2018 (fl. 122).

Os réus foram citados (Jeferson - fl. 141; Tunesley - fl. 146), e apresentaram resposta à acusação (Tunesley - fls. 161/162; Jeferson - fls. 175/176).

Foi designada audiência de instrução, debates e julgamento, onde foram ouvidas a vítima, as testemunhas e, ao final, os réus foram interrogados.

O Ministério Público requereu a parcial procedência da denúncia, com a condenação do acusado Tunesley.

As defesas requereram a absolvição dos acusados.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O processo encontra-se formalmente em ordem, estando presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. Não havendo nulidades ou vícios a serem sanados. Os réus foram representados por Defensores e foram observados os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Não há questões preliminares a serem analisadas. Assim, passo à análise do mérito.

A pretensão ministerial é IMPROCEDENTE.

Apesar dos documentos juntados aos autos- inquérito policial (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 04/05), termo de declarações (fls. 07/08; 12/15), auto de reconhecimento fotográfico (fl. 09), documentos de instauração e apreensão (fls. 10/11), relatório de investigações (fls. 16/17), termo de depoimento (fl. 26), auto de avaliação (fl. 43), auto de qualificação e interrogatório (fls. 63/69), auto de qualificação indireta (fls. 88/93), relatório final (fls. 107/111)- a materialidade

a autoria não ficaram comprovadas, com absoluta certeza, pelas provas produzidas nos autos. Vejamos.

Rafaela Fernanda Costa (vítima) disse que, nessa época, tinha 18 anos. O aparelho telefônico era da depoente. Estava na rodoviária com os outros dois réus, que são usuários. Começaram uma desavença. Tusley partiu para cima do depoente e a depoente começou a se debater. Ele pegou o celular. O celular estava em nome da mãe. Quem pegou o celular foi Tuesley. A outra pessoa é conhecida por Bolinha, mas não sabe o nome. Bolinha ficou olhando. Bolinha não cobriu a boca, nem impediu que reagisse. Quando estavam discutindo, ficou falando para o guarda da rodoviária separar e ele não entrou no meio. Tusley levou o celular e a genitora registrou o boletim de ocorrência. O celular era da mãe, mas o B.O. foi registrado no nome da depoente. Depois de um tempo, conversou com Tuesley, foi um mal entendido. Ficou com o prejuízo. Com 18 anos, a depoente fumava maconha e começaram a desavença. Ele queria comprar pedra a depoente não tinha dinheiro. Ele pegou celular para comprar drogas. Estava na rodoviária para esperar um amigo. Esse amigo chegou depois que tudo que aconteceu. Quando o amigo chegou, a depoente estava na delegacia. Todo o desentendimento aconteceu na rodoviária. Não teve perseguição. Tinham uma convivência. No dia, estava na rodoviária esperando o amigo e coincidiu dos dois estarem ali. Ele queria comprar o crack que a depoente usava para usar. Quando falou que não tinha crack, ele falou que iria pegar o celular. Ficaram segurando o celular e, de repente, ele puxou. Ele segurou de um lado e a depoente segurou do outro e ficaram tentando puxar. A outra pessoa não fez nada, só ficou olhando. Tuesley tentou cobrir a boca da depoente para não gritar. Ninguém a segurou nenhum momento. Ele conseguiu segurar o celular e ficaram se debatendo. Depois que ele pegou o celular, ele foi embora. Não queria fazer o boletim de ocorrência. Mas a mãe quis que fizesse o boletim de ocorrência. Tuesley ameaçou Jacaré. Falou para Tuesley que cada um deveria seguir seu rumo. Não se sentiu ameaçada ou com medo de Tuesley. Depois que saiu na delegacia, continuou a ter contato com Tuesley. Não está mudando a versão para ajudá-lo. Ele não ressarcir o valor do celular. O celular foi trocado por drogas. Bolinha só ficou olhando. Não tinha muito problema com drogas. Acredita que a abstinência estava forte naquele dia.

Eduardo Roberto Conceição (testemunha de acusação) disse que não se recorda muito bem dos fatos. Participou de alguns delitos que envolveram Tuesley e o outro rapaz. Não lembra exatamente como estava no relatório. Pelo que se recorda, ela conhecia Tuesley, ambos teriam se encontrado para usar entorpecentes. Depois, ambos queriam mais drogas, mas como Tuesley não tinha mais entorpecentes, ele teria proposto o acordo: dar o celular para vender, ela ofereceu resistência e, mesmo assim, pegaram o celular e entregaram o celular na biqueira. Lembra-se de um segurança ter tentado falar algo, mas não se recorda o que foi feito.

Arnaldo Maritan Filho (testemunha de acusação)- testemunha faleceu em 10/05/2021. Tuesley Silva Cunha (réu) disse que 31 anos. Trabalha registrado em uma empresa. Ganha R\$ 1800,00. É solteiro. Não tem filhos. Na época, era usuário de drogas, estava em situação de rua. Não roubou ninguém. A Rafaela vendia entorpecentes para o depoente. Na época, estava em situação de rua e ganhava muito lanche. Pegava lanche, ia ao local e ela lhe dava entorpecente em troca. Ela fazia a venda e consumo de entorpecentes no terminal. Ela deu o telefone para consumirem drogas juntos. Nesse dia, estava com Jefferson, usando drogas. Usava drogas todos os dias. Pelo que se lembra, ela chegou e queria o cachimbo emprestado para consumir crack. Entraram para dentro do mercado e começaram a consumir drogas. Tinha um pouco de drogas e consumiram juntos. Na época, Rafaela vendia o entorpecente. Ela era usuária e vendia. Assim que ela entrou, ela ofereceu o telefone para avaliar na biqueira se poderia fazer a troca. Não usaram de violência física ou ameaça para pegar o celular. O telefone não era da Rafaela, era da mãe dela. A genitora queria que o depoente voltasse na biqueira para pegar o telefone. Ficou sabendo pela mãe da Rafaela que o celular não era dela. Ela entregou o celular espontaneamente ao depoente. Após o término do consumo, acredita que ela se arrependeu e iniciou-se uma discussão. A discussão foi porque deu o celular e, depois, arrependeu-se. A discussão ocorreu na rodoviária. Não se recorda se Jacaré, guarda chamado Arnaldo que ficava no terminal, estava naquele dia. Os três estavam sob efeito de crack no

dia. Rafaela estava sob efeito de drogas quando chegou. Depois desses fatos, não viu mais Rafaela. Não agrediram Rafaela, nem a ameaçaram de morte. Jacaré não tentou interferir. Conhece Arnaldo, porque morou no mercado. Não tinha um relacionamento agradável com Arnaldo, sendo que um não gostava do outro. Quando pegou o celular, saiu andando, e não correndo. Na época, era usuário de crack. Não tinha controle da vida. Hoje, está recuperado e está mudando sua vida aos poucos. Arnaldo não gostava muito do depoente porque era morador de rua e usuário de drogas.

Jeferson Caetano Penha (réu) disse que tem 26 anos. Está preso desde janeiro de 2017. Já foi registrado, mas, na época, era ajudante de pedreiro. É solteiro. Tem filhos menores de idade, de 8 anos. Disse que tem muito tempo. Recorda-se que, na data, era acostumada a ficar com Tuesley no supermercado abandonado. Estavam fazendo uso de entorpecentes e ela chegou querendo fumar. Fumaram, ela deu 20 reais e foram fumar mais. Ela disse que ia entregar o celular quando as drogas acabassem. Ela entregou o celular e os dois foram para biqueira vender. Depois, acha que ela se arrependeu, e começou a gritar, dizendo que tinham roubado. Em momento algum, roubaram o celular. Ela mesma entregou o celular. Inclusive, 4/5 dias depois, a mãe dela apareceu na biqueira e contaram o que aconteceu. A mãe dela pediu que não era para deixar Rafaela aparecer lá. Não pegar o celular com força. Rafaela entregou com as próprias mãos. Depois, ela se arrependeu e disse que não iriam devolver, porque ela já tinha usado a droga. Não usaram de violência para pegar o celular, porque ela entregou o celular para trocar por drogas. Não usaram violência ou ameaça física. É conhecido como Bolinha, desde pequeno. Não a conhecia na época, era Tuesley que a conhecia. Segundo a mãe dela falou, 4/5 dias depois do ocorrido, o celular era da genitora. A mãe dela é que tinha pegado. Rafaela não chegou a falar que o celular era da mãe dela. Na data, sempre ficava um vigilante na rodoviária. Passaram na rodoviária no momento em que ela estava arrependida, pedindo o celular de volta. Ela entregou o celular e, depois, os dois saíram andando. O celular não foi tomado. Não tinha motivo para correr. Não houve agressão. Assim que ela entregou o celular, foram à biqueira. Trocaram o celular e voltaram para biqueira, mas a vítima não estava mais ao local.

Finda a instrução processual, as provas produzidas nos autos são insuficientes para fundamentar um decreto condenatório. Vejamos.

Ouvidos na fase extrajudicial, os acusados narraram que a vítima, após usar entorpecentes com o réu Tuesley, deu seu aparelho celular para Tuesley comprar cinco gramas de crack. Quando estavam indo embora, a vítima pediu o celular de volta, porém, negaram devolvê-lo, momento em que Rafaela tentou tomar a força, mas o acusado Jeferson interveio segurando-a e tampando sua boca para que ela não gritasse. Após, se deslocaram até o bar do "Vanánias", e venderam o aparelho celular por R\$ 50,00 (cinquenta reais).

Em juízo, durante os seus interrogatórios, os acusados, novamente, negaram a subtração do celular, mediante violência e grave ameaça. Reiteraram a o depoimento prestado durante o inquérito policial, informando que a vítima, espontaneamente, forneceu o seu celular, para trocarem por drogas, com a finalidade de juntos a consumirem. Acrescentaram que, posteriormente, Rafaela se arrependeu e passou a exigir a devolução do celular.

O depoimento prestado pelos réus não pode ser afastado, com absoluta certeza, pelas provas produzidas nos autos.

Isto porque, a versão judicial da vítima é totalmente diferente da narrativa apresentada durante o inquérito policial. Quanto ao acusado Jefferson, a vítima negou expressamente a sua participação. Declarou que Jeferson somente observou a situação, mas nada fez. Questionada, negou expressamente que Jeferson tivesse coberto a sua boca ou a segurado para que Tuesley retirasse o aparelho celular de suas mãos.

Por sua vez, em relação a Tuesley, a ofendida negou que tenha dado o celular espontaneamente. Disse que não concordou em ceder o celular para o acusado e que o celular foi retirado sem o seu consentimento. Porém, em um depoimento confuso, contraditório e repleto de inconsistências, declarou que não houve perseguição, uso de violência ou grave ameaça.

A testemunha Eduardo, policial civil, trouxe parcos esclarecimentos quanto aos fatos narrados na denúncia. Disse que não se recordava com precisão dessa investigação. Todavia, declarou que, aparentemente, houve uma discussão envolvendo os acusados e a vítima, em razão do uso de entorpecentes, versão que reforça e corrobora o depoimento dos réus.

Ainda, o testemunho de Arnaldo não pôde ser confirmado em juízo, sob o crivo do contraditório, pois a testemunha faleceu no curso do processo. Aliás, relevante destacar que o réu Tunesley indicou que não tinha um bom relacionamento com Arnaldo. Logo, a vítima e a testemunha de acusação, ouvidas em juízo, não trouxeram elementos suficientes para confirmar os fatos descritos na denúncia. De fato, as provas colhidas sobre a égide do contraditório não permitem inferir, com absoluta certeza, a responsabilidade penal dos réus. A acusação não se desincumbiu de seu ônus de fazer prova robusta a autorizar o decreto condenatório. A suspeita e a dúvida não bastam e, se dúvida houver, esta é valorada em favor dos réus em razão do princípio do estado de inocência.

Importante destacar que o Código de Processo Penal, em seu artigo 155, caput, prevê o princípio do livre convencimento motivado, pelo qual o magistrado irá analisar o caso e julgá-lo conforme as provas trazidas aos autos, mas terá discricionariedade para a sua valoração, distinguindo-se, portanto, do princípio da convicção íntima e da prova tarifada. Conforme assinala Guilherme de Souza Nucci:

"(...) a persuasão racional é o método misto, também chamado de convencimento racional, livre convencimento motivado, apreciação fundamentada, ou prova fundamentada. Trata-se do sistema adotado, majoritariamente, pelo processo penal brasileiro, que encontra, inclusive, fundamento na Constituição Federal (artigo 93, inciso IX), significando permissão dada ao juiz para decidir a causa de acordo com o seu livre convencimento, devendo, no entanto, cuidar de fundamentá-lo, nos autos, buscando persuadir as partes e a comunidade em abstrato (NUCCI, 2008, pag. 339).

Todavia, a segunda parte do artigo 155, caput, CPP, estabelece que a decisão judicial não pode ser fundamentada, em regra, exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação, ou seja, os elementos probatórios colhidos em sede policial precisam ser confirmados pelas provas produzidas através da dilação probatória realizada em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Assim, os depoimentos apresentados são suficientes para gerar uma dúvida fundada sobre a autoria das infrações penais. A dúvida razoável deve ser resolvida em favor dos acusados. O conjunto probatório não se mostrou apto a embasar uma condenação contra os réus e a aplicação do princípio in dubio pro reo, a justificar uma absolvição, é medida que se impõe. Nesse sentido, são os julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

Apelação. Uso de documento falso. Absolvição por insuficiência de provas. Viabilidade. Ausência de exame pericial apto a comprovar a falsidade dos documentos. Elementos que não comprovam o conhecimento pela ré da suposta falsidade dos atestados, bem como de que os apresentou à empregadora nesta condição. Dúvida razoável que deve prevalecer em favor da acusada. Insuficiência probatória caracterizada, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Aplicação do princípio in dubio pro reo. Recurso provido. (Apelação 0056565-41.2011.8.26.0602. Relator(a): Leme Garcia. Comarca: Sorocaba. Órgão julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal. Data do julgamento: 08/03/2016. Data de registro: 10/03/2016).

Apelação. Tráfico de drogas. Absolvição por insuficiência probatória. Necessidade. Ausência de elementos que comprovem a participação do apelante na traficância. Corréu que assumiu isoladamente a propriedade dos entorpecentes. Dúvida razoável que deve prevalecer em favor do acusado. Insuficiência probatória caracterizada, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Aplicação do princípio in dubio pro reo. Recurso provido. (Apelação 0000062-31.2013.8.26.0278.

Relator(a): Leme Garcia. Comarca: Itaquaquetuba. Órgão julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal. Data do julgamento: 14/06/2016. Data de registro: 14/06/2016).

HOMICÍDIOS CULPOSOS E LESÕES CORPORAIS CULPOSAS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - DÚVIDAS QUANTO À REAL RESPONSABILIDADE DO RÉU NA PROVOCAÇÃO DO ACIDENTE - POSSIBILIDADE. Inexistindo prova segura a lastrear o decreto condenatório, de rigor a absolvição, face ao princípio do in dubio pro reo. RECUSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO. (Apelação 0005445-33.2012.8.26.0566.

Relator(a): Willian Campos. Comarca: São Carlos. Órgão julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal. Data do julgamento: 14/04/2016. Data de registro: 18/04/2016).

Ressalte-se, uma vez mais, que a autoria se mostrou duvidosa, pois a condenação não pode se fundamentar em juízo de probabilidade. Não havendo plena certeza acerca da prática da conduta típica e antijurídica atribuída aos acusados, impõe-se a absolvição, como medida acautelatória do bem jurídico vital do homem, isto é, a sua liberdade. Na dúvida, a garantia da liberdade sempre deve prevalecer sobre o poder punitivo estatal.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para ABSOLVER os réus TUESLEY SILVA CUNHA, portador do R.G. n.º 47.056.469 - SP, filho de Izaias Silva Cunha, nascido em 08/04/1990 em Açailândia- MA; e JEFERSON CAETANO PENHA, portador do R.G. n.º 44.627.157-3 - SP, filho de Flavio Penha e Joana Caetano de Jesus, nascido em 26/03/1996 em José Bonifácio- SP, das sanções do artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Custas na forma da lei.

Após o trânsito em julgado, procedam-se às anotações e comunicações necessárias, arquivando-se os autos.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Após a prolação da sentença, foram questionadas as partes acerca do interesse em recorrer. Em seguida, pelo(a) Dr(a). Promotor(a) foi dito que não haveria interposição de recurso por parte do Ministério Público. Em seguida, pelo(a) pelo(a) réu(ré) Jeferson Caetano Penha e por sua defensora foi dito de forma expressa e verbal: renunciemos ao direito de recorrer. Em seguida, pelo(a) pelo(a) réu(ré) Tuesley Silva Cunha e por seu defensor foi dito de forma expressa e verbal: renunciemos ao direito de recorrer. Em seguida, pela MMª. Juíza de Direito foi dito que: homologo as renúncias das defesas. Certifique-se o trânsito em julgado para a acusação e para as defesas. Cumpra-se a sentença, expedindo-se o necessário. Regularizados, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Daniel Dezan Imazawa, matrícula 819.980, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.